

1500614-06.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500614-06.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500614-06.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045571/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 23071494 - 02º D.P. GUARUJA, 2045571 - 02º D.P. GUARUJA, AJ7519-1/2022 - 2º

Distrito Policial de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID GABRIEL LORENA CLAUDINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

David Gabriel Lorena Claudino, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 16:05 horas, na Rua Barão do Rio Branco, nº 248, Parque Estuário, nesta cidade e comarca de Guarujá, trazia consigo, para o fim de entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) porções de cocaína, substância ilícita que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante o auto de constatação preliminar de fls. 6.

O réu apresentou defesa prévia, através de seu advogado constituído (fls. 66/67,

80), que não comportou acolhimento e a denúncia foi recebida (fls. 98). O réu foi citado (fls. 137).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 83/85).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 150). E encerrada a instrução, pelas partes nada foi requerido, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 148).

A representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 153/156).

Nos memoriais, a defesa requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Permanecendo diverso o entendimento, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06 - em seu patamar máximo - pela fixação do regime inicial aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como pela concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 160/168).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, pelo boletim de ocorrência de fls. 2/4, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5, pelo auto de constatação preliminar de fls. 6, pelas fotografias de fls. 8/9, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 83/85, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado na fase policial, o réu confessou a prática delitiva. Relatou que por volta das 16:00 horas se encontrava na Praça 14 Bis, vendendo droga. De repente, os policiais militares chegaram ao local dos fatos e flagraram o interrogando comercializando a substância entorpecente, a qual se encontrava em uma das mãos do acusado, e foi apreendida pela Polícia. Dos R\$ 214,30 (duzentos e catorze reais e trinta centavos) apreendidos em sua posse, afirmou que R\$ 100,00 (cem reais) lhe pertenciam, e o restante era produto da venda de entorpecente (fls. 12).

Em seu interrogatório judicial, o réu alterou sua versão sobre os fatos, e negou a prática delitiva. Relatou que a droga que portava era para o consumo pessoal. Os policiais militares chegaram ao local dos fatos desferindo chutes no interrogando e ordenando que se deitasse no solo. Por temor, o acusado confessou que era traficante para parar de apanhar, mas é tão somente usuário. Quando a Polícia chegou ao local, os traficantes correram todos para a padaria. Já foi abordado anteriormente pelos mesmos policiais, os quais chegaram a pedir dinheiro ao interrogando. Não se recorda de ter falado ao Delegado de Polícia que traficava há 3 meses (fls. 150).

Pois bem, na fase extrajudicial o réu confessou a prática do delito e, em juízo, o réu modificou sua versão, passando a negar a prática delitiva. Entretanto, deve prevalecer a confissão extrajudicial do réu, que restou corroborada pelas demais provas dos autos. As provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram a autoria delitiva do réu e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Maécio Simplicio Teixeira, no seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento de rotina na Presidente Vargas, acompanhado do policial Danilo Penna. Quando chegaram à Rua Barão do Rio Branco, o depoente visualizou o acusado perto de uma banca de jornal segurando algo na mão, em atitude suspeita. O acusado avistou a viatura policial e demonstrou nervosismo. A equipe deliberou pela abordagem do réu e durante a revista pessoal, quando determinaram que ele abrisse a mão, constataram que o acusado tinha em sua

posse o valor de R\$ 208,00 (duzentos e oito reais) em cédulas trocadas e R\$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) em moedas. E na outra mão, dentro da pequena sacola verde que segurava, havia 6 porções de cocaína, embaladas unitariamente, prontas para a venda. Indagado a respeito, o acusado confessou que a droga apreendida era destinada à venda e que o dinheiro apreendido era produto da comercialização dos papелotes de cocaína. O local dos fatos é conhecido ponto de traficância. O depoente não conhecia o acusado anteriormente aos fatos (fls. 150).

Danilo Penna Carneiro, policial militar, em juízo, relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento preventivo com seu colega Maécio Simplicio, e quando passaram pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado em atitude suspeita, segurando algo em ambas as mãos. Quando o acusado notou a chegada da viatura policial, demonstrou nervosismo e fechou a mão bruscamente, levando-a para trás de seu corpo. A equipe decidiu abordá-lo e, na revista pessoal, foi constatado que o acusado segurava dinheiro em uma mão e droga na outra. Havia cédulas trocadas e também moedas. O acusado confessou que estava comercializando cocaína e que o dinheiro com ele encontrado era produto da traficância. Então, o réu recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido perante a autoridade policial. O depoente não conhecia o acusado anteriormente aos fatos (fls. 150).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição. A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da forma de acondicionamento da droga, do dinheiro em cédulas trocadas encontrado na posse do réu, e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do acusado, que estava em local conhecido pela venda de drogas, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória. Ainda, na fase policial o réu confessou os fatos narrados na denúncia.

Importante ressaltar que o fato da confissão do réu ter ocorrido apenas em fase extrajudicial não afasta seu valor probatório, pois a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, bem como pela prova material. Com efeito, a confissão extrajudicial não pode ser descartada quando confirmada pelo restante do conjunto probatório.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado trazia consigo os entorpecentes, e os entorpecentes eram destinados para a entrega a consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias entorpecentes para sustentarem o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

A propósito:

"(...) Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo,

infelizmente, comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de financiar seu vício (...)." (TJSP, Apelação nº 0000136-06.2016.8.26.0626, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Damião Cogan, julgado em 10/05/2019)

Nesse sentido, ainda:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (TJSP - HC 42.229-3 -Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498)

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, uma vez evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à entrega para consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a primariedade do réu e a pequena quantidade do entorpecente apreendido (1,4 g, fls. 83/85), entendo que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade do acusado, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, mas deixo de aplicá-la, pois a atenuante não pode levar a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, em relação à aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o acusado preenche os requisitos legais, pois apresenta a condição de primário, não possui antecedentes (fls. 40/42), e inexistem indícios de que integre organização criminosa. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, o réu trazia consigo pequena quantidade de cocaína (1,4 g, fls. 83/85), que apesar de seu alto poder viciante, não foi uma quantidade elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreram os fatos, a dedicação habitual do acusado à atividade criminosa, e que faz do tráfico de drogas um meio de vida. Tampouco se comprovou que o réu integra organização criminosa. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria penal aplico o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a reprimenda em 2/3, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Ausentes dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do STF decidiu recentemente que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do

privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução). "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cumprir destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou da suspensão condicional da pena - nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal - pois não se mostram medidas suficientes e adequadas ao presente caso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra David Gabriel Lorena Claudino para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial competente com a determinação de destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão

de fls. 5, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram tratar-se de instrumentos do tráfico ilícito de entorpecentes. Oficie-se à autoridade policial competente comunicando, após o trânsito em julgado. No que tange ao valor apreendido, decreto o perdimento em favor da União, vez que se trata de produto do tráfico de drogas. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para o cumprimento. Custas na forma da Lei. P.I.C.

Guaruja, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA